

0002869-75.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Diego Guiaro de Moraes e Eduardo Henrique Aparecido de Sousa, foram uníssomos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento pelo Bairro União, ocasião em que visualizaram um casal próximo a um ponto de ônibus, num local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Quando o rapaz notou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002869-75.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002869-75.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 2463/2021 - Delegacia de Polícia de Itu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eric Ramos de Almeida

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu ERIC RAMOS DE ALMEIDA como incursos no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06 c.c. o art. 40, inciso VI (adolescente), da Lei Federal no 11.343/06 e com o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 21h55min, na Rua Vaticano, nº 470, Jardim União, nesta cidade e comarca de Salto/SP, agindo em concurso com a adolescente Mayara Kelly Aparecida Betoldo, previamente ajustados e em unidade de desígnios, em ocasião de calamidade pública, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 15 (quinze) porções de "crack", com peso líquido de 7,99g (sete gramas e noventa e nove centigramas); e b) 01 (um) frasco com "diclorometano", substância conhecida como "lança perfume", com volume de 5ml (cinco mililitros), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 03 de novembro de 2021 (fls. 71-74).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 95-96).

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fl. 98-99).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas 05 (cinco) testemunhas, duas comuns e 03 (três) arroladas pela defesa.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07-09), auto de exibição e apreensão (fl 10), auto de constatação preliminar (fls. 11) e laudo de exame químico toxicológico (fls.92-94), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Diego Guiaro de Moraes e Eduardo Henrique Aparecido de Sousa, foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento pelo Bairro União, ocasião em que visualizaram um casal próximo a um ponto de ônibus, num local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Quando o rapaz notou que se aproximava a viatura, passou a caminhar no sentido contrário ao da viatura, já a garota sentou-se no ponto de ônibus. Realizada a abordagem, foram localizados um microtubo de plástico contendo cocaína, um frasco pequeno de “lança-perfume” e vinte reais em espécie. Com Mayara, foram localizados no bolso da blusa, 14 microtubos plásticos contendo cocaína e dez reais em dinheiro. Mayara disse que havia acabado de conhecer Eric e que havia combinado com ele de ajuda-lo na venda de drogas, sendo que enquanto ele vendia os entorpecentes, ela guardava o remanescente. Já Eric alegou que não conheci Mayara, alegando que tinha acabado de adquirir um pino de cocaína e um frasco de lança perfume para seu consumo.

A testemunha Bruno Mendes de Sá disse ser amigo de infância do acusado e prestou depoimento abonatório da conduta do réu. Disse ainda que o réu é usuário e sempre vê a menor no local, acredita que ela vende drogas ali. Não sabe o nome da adolescente ou onde ela mora. Ela é morena e baixinha, aparenta ser menor de idade. Não sabe se Eric a conhece. Passa no local na volta do trabalho.

A testemunha Ivanir Ramos é genitora do acusado, prestou depoimento sem firmar compromisso. Disse que o acusado é usuário de drogas e prestou depoimento abonatório da conduta do réu. .

O réu, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que estava bêbado, foi comprar drogas. Comprou cocaína e lança-perfume. Mayara vendeu a droga ao acusado.

É possível considerar os elementos de prova produzidos na fase inquisitiva, conforme art. 155 do Código de Processo Penal. Mayara Kelly Aparecida Betoldo, na fase policial (fls. 04), disse que conhece Eric de vista e na data dos fatos estava indo a um trailer, o encontrou e caminhavam juntos quando avistaram uma viatura da Guarda Municipal, Eric entregou a declarante pinos soltos de cocaína para que ela colocasse nos bolsos e se separaram. Ambos foram abordados e conduzidos ao plantão policial. Não é usuária de drogas e desconhecia que Eric comercializava tais substâncias.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo mais de uma dezena de porções de “crack”, todas individualmente embaladas, e um frasco de “lança perfume”, e ao notar a aproximação da viatura da Guarda Municipal entregou para a adolescente Mayara. Além disso, frisaram que anteriormente receberam denúncias de que o acusado estaria traficando no local.

O simples fato de o réu alegar ser usuário não o impede de exercer a traficância, o que também, aliás, não se mostra incomum. Convém ressaltar a cautela habitual desenvolvida pelos traficantes com o propósito de serem confundidos com usuários. Desse modo, é incomum tais agentes serem abordados com grande quantidade de entorpecente, pois na maioria das vezes agem arditosamente, armazenando a maior parte da droga em outro local, no caso dos autos, entregando a maior parcela de

droga a adolescente, o que não deve ser interpretado em seu favor, mormente diante da existência de elementos probatórios corroborando um cenário de traficância. As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

E mais, inexiste dispositivo que os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizerem a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos, pelo contrário, sendo eles investidos em cargo público, o ordenamento jurídico lhes confere presunção de veracidade em suas declarações relacionadas ao exercício de sua função, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência:

"Os agentes públicos não se encontram impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos em que tenham atuado na fase investigatória, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando corroborados por outros elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal. A respeito ensina Guilherme de Souza Nucci: "[...]preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho." A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que "é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (...) Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ - HC: 618963 MS 2020/0269911-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 02/12/2020)

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, as drogas e valor em dinheiro apreendidos denotam o intuito mercantil, corroborados pelos depoimentos dos guardas municipais e confirmados pela terceira Mayara Kelly Aparecida Betoldo são suficientes a embasar o decreto condenatório, não sendo crível que tais pessoas mentissem apenas para prejudicar o réu. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.)

Essa é a maciça posição do Superior tribunal de Justiça, a saber:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 8 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 9 QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

A Lei Federal no 11.343/06, art. 40, inciso VI, conferindo uma maior reprovabilidade da ação, prevê aumento de pena para o traficante que, no sentido de atuar conjuntamente, em concurso eventual, utiliza ou conta com a participação de criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Nota-se que, confirmado pelo depoimento da adolescente, é possível concluir que o réu se aproveitou de sua maior suscetibilidade para entregar-lhe os microtubos de cocaína para que os guardasse, com o intuito de ser confundido com usuário. Nessa lógica, mister o reconhecimento da causa de aumento de pena, em patamar mínimo. No mesmo rumo, o seguinte precedente:

"Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública, juntamente com um adolescente, na posse de 85 porções de cocaína, com peso total de 23g; 59 porções de maconha, pesando 180,1g; 7 frascos de lança-perfume, com volume líquido total de 339 mililitros; e um comprimido de ecstasy, com peso de 0,32g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Básica fixada no piso. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante. (TJSP; Apelação Criminal 0006695-78.2018.8.26.0635; Relator

(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

Salienta-se, por fim, que a partir do julgamento do HC 97.256 pelo STF, quando foi declarada incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 33 e do artigo 44 da Lei de Drogas, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Seguindo esse posicionamento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STJ:

“Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado parado no meio da rua em local conhecido pelo comércio espúrio. Apreensão de 41 porções de cocaína, com peso de 33,30 gramas, além de R\$ 155,00. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão. Regime aberto. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1500864-37.2019.8.26.0603; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA IMPOSTA PARA UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. TIPO PENAL AO QUAL É COMINADA PENA DE MULTA CUMULATIVA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRIORIDADE À SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ANALOGIA À SÚMULA 171/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese na qual a instância ordinária, de forma motivada, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a variedade das drogas apreendidas (89 micropontos de LSD e 30 comprimidos de ecstasy), exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional. Precedentes STJ e STF. 3. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu. 4. O preceito secundário do crime pelo qual o paciente foi condenado (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006) já estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, de modo que se deve privilegiar na substituição a escolha da pena restritiva de direito, em observância à Súmula 171/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 643.390/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Federal no 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Considerando a primariedade, a quantidade de drogas apreendidas (7,99 g e um frasco de lança-perfume), o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa e, tendo em vista que a participação da adolescente, por si só, não

indica que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da quantidade das penas aplicadas, as circunstâncias judiciais favoráveis e, sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu ERIC RAMOS DE ALMEIDA à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Faculto a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.

Expeça-se alvará de soltura.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA